

1500184-88.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500184-88.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

JOÃO PAULO MENEZES CUNHA e NATANAEL DOS SANTOS

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

JOÃO PAULO MENEZES CUNHA e NATANAEL DOS SANTOS foram denunciados e estão sendo processados como incurso artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 18 de junho de 2021, por volta das 10h46min, na Avenida Edith Prettyman Moreira, 1, São Pedro, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 30 (trinta) porções de maconha (Cannabis sativa L), 12 (doze) sacos de cocaína, 34 (trinta e quatro) eppendorfs de cocaína e 200 (duzentas) pedras de crack, derivado da cocaína fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 15.09.2021 (pág.137).

Os réus foram citados (págs. 144 e 146) e apresentaram resposta escrita à acusação (págs. 156/158).

Foi declarada à revelia do réu JOÃO PAULO em razão deste não ter comparecido em audiência apesar de devidamente intimado. (págs. 178/179).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu NATANAEL (págs. 178/179).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos às págs. 124/125.

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-os nos exatos termos da denúncia.

A defesa de Natanael, por sua vez, requereu seja a demanda julgada improcedente, subsidiariamente, seja aplicada a atenuante de confissão espontânea.

A defesa de João Paulo, requereu seja a demanda julgada improcedente e o acusado absolvido e, caso não seja esse o entendimento, que sejam aplicados o tráfico privilegiado e o início da pena em regime aberto para substituir a pena privativa liberdade por duas penas restritivas de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 03/04), pelo boletim de ocorrência (págs. 09/12), pelo auto de exibição e de apreensão (págs. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (págs. 15/16), pelo laudo químico- toxicológico (págs. 109/111), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e atribuída aos acusados.

A testemunha arrolada pela acusação, Ana Karoline Batista de Jesus, ouvida em Juízo, Policial Militar, disse que receberam via COPOM uma denúncia de que havia 03 (três) indivíduos traficando no local dos fatos. Em diligência, visualizaram o corréu João Paulo, que era o olheiro, mas em sua posse nada de ilícito fora encontrado. Contudo, em busca pelo local, foi possível lograr êxito em localizar o corréu Natanael em um terreno baldio e com ele fora encontrado uma sacola plástica com entorpecentes. Asseverou que os acusados confessaram informalmente a traficância. Afirmou não que não os conhecia anteriormente aos fatos.

A testemunha arrolada pela acusação, Edmilson Lopes Araújo, ouvido em Juízo, Policial Militar, narrou os mesmos fatos que sua colega de farda, aduzindo que as características dos acusados correspondiam com as informadas em denúncia.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"A alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-la, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar os réus. Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa do natural apenas com o intuito de justificar as suas ações. E, pequenas divergências existentes entre as declarações prestadas pelos policiais militares não bastam, por si sós, para infirmá-las. 'O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E

a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 Relator Des. Pinheiro Franco 5ª Câm. V.U. 31.07.2008)'. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição. Aferes-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111) 'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

O réu, Natanael dos santos, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que estava em situação de rua e recebeu uma proposta de um terceiro indivíduo e de João Paulo, para vender as drogas em troca de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e drogas.

Pois bem.

A responsabilidade penal dos réus é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos e a confissão espontânea do acusado Natanael, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor dos réus.

Passo a dosar a pena.

RÉU JOÃO PAULO MENEZES CUNHA

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág. 44) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...]" (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes, desse modo, mantenho a pena mínima em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Anote-se que a quantidade de drogas apreendidas impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente,

vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda."

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Todavia, a grande quantidade de droga envolvida é indicativo, por si só, de que o acusado efetivamente se dedicava a atividade criminosa, integrando organização criminosa, posto que é insustentável que um traficante iniciante tenha condições financeiras (lucro próprio do tráfico), para adquirir, fracionar e embalar sozinho, tamanha quantidade de entorpecentes, concluindo-se que o corréu Natanael, ou recebeu as drogas de pessoa hierarquicamente superior na organização criminosa, ou a muito tempo vem comercializando as drogas, a ponto de ter dinheiro o suficiente para adquirir a grande quantidade apreendida. Tornando prova apta a indicar que este seria o seu meio de sustento, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉU NATANAEL DOS SANTOS

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 46/56), observo que o réu possui maus antecedentes. Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, como também a agravante da reincidência, conforme certidão (págs. 58/62), que é considerada preponderante sobre a atenuante conforme regra expressa do artigo 67 do Código Penal. Diante disso, exacerbo a pena base em apenas 1/3 (um terço), resultando uma pena provisória de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de

primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda."

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes".

Desta forma, o réu sendo reincidente impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Dito isso, presente a agravante da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), pela suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I e III do Código Penal), e a aplicação dos regimes aberto e semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal).

Assim, também o regime inicial de cumprimento será o fechado.

Posto isto, CONDENO o réu JOÃO PAULO MENEZES CUNHA qualificado nos autos, ao cumprimento, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

CONDENO o réu NATANAEL DOS SANTOS qualificado nos autos, ao cumprimento 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa., no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu Natanael respondeu preso ao presente processo e por estar presente os requisitos da custódia cautelar, não poderá recorrer em liberdade. Ao passo que o corréu João Paulo, respondeu ao processo solto e poderá assim permanecer em eventual recurso.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Arbitre os honorários dos defensores nomeados, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expedindo-se o necessário.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 26 de maio de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA